

Historia e instituciones del Derecho Romano

Romina Del Valle Aramburu

FRANJA
MORADA

Aramburu Córdoba, Romina del Valle

Historia y derecho del legado romano / Romina del Valle Aramburu Córdoba. -
1a ed. - La Plata: EDULP, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8348-31-5

1. Derecho Romano. I. Título.

CDD 340.09

Iuris Romanorum: Historia e instituciones del Derecho Romano

ROMINA DEL VALLE ARAMBURU CÓRDOBA



EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (EDULP)

48 N° 551-599 4° Piso/ La Plata B1900AMX / Buenos Aires, Argentina

+54 221 644-7150

edulp.editorial@gmail.com

www.editorial.unlp.edu.ar

Edulp integra la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales (REUN)

ISBN 978-987-8348-31-5

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

© 2020 - Edulp

Impreso en Argentina

A mis padres Rosa del Carmen Córdoba y Domingo Aramburu

A mi Hijo Luis Jorge Alan

A mi hermano Sergio

A Paola Zini Haramboure

A todos/as aquellos/as que hicieron posible la concreción de éste libro.

FRANJA
MORADA

CONTENIDO

PRÓLOGO	8
Presentación	14
Capítulo I	
La Monarquía	16
Capítulo II	
La monarquía: Orígenes. Leyenda y sus críticas	40
Capítulo III	
El Imperio.....	120
Capítulo IV	
Las Fuentes del Derecho: Las Compilaciones.....	151
Capítulo V	
El derecho post cultura jurídica romana.....	167
Capítulo VI	
La persona. Relevancias jurídicas.....	185
Capítulo VII	
La familia y el matrimonio romano	237
Capítulo VIII	
Tutela y Curatela.....	281
Capítulo IX	
El derecho Hereditario.....	296

Capítulo X	
El negocio jurídico	324
Capítulo XI	
Los derechos patrimoniales	337
Capítulo XII	
Derecho real sobre cosa propia: La propiedad	362
Capítulo XIII	
Derechos reales sobre la cosa ajena.....	403
Capítulo XIV	
Derechos reales sobre la cosa ajena.....	421
Capítulo XV	
Derechos personales: Las obligaciones.....	432
Capítulo XVI	
Fuentes de las obligaciones	443
Capítulo XVII	
Los Contratos.....	480
Capítulo XVIII	
Efectos y extinción de las obligaciones.....	494
Capítulo XIX	
El proceso judicial privado romano.....	509

Palabras clave: Historia, Familia, Sucesiones

La gozosa tarea de hacer la presentación de un libro a solicitud de su autora representa un honor, y al propio tiempo, un reto, ya que obliga al protagonista a hacer un ejercicio de dominio académico, de experiencia dilatada sobre una materia que sale de la imprenta con la lozanía y perfección que todo investigador persigue. Así las cosas, y como exordio a mi querido oficio de prologuista, quisiera poner de manifiesto las múltiples y heterogéneas razones que hacen especialmente atractiva a mi persona tomar la pluma para afrontar el encargo. Lo haré con brevedad siguiendo el imperativo gracianesco, porque en los banquetes exquisitos los aperitivos huelgan. Ante todo, me he sentido obligado a ello por un deber de *amiticia* lo cual, entre romanistas que comprendimos cabalmente el hondo significado de tal vocablo, constituye un deber sagrado e inviolable. Conocí a la profesora Romina del Valle Aramburu Córdoba, con motivo de los congresos anuales de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina (A.D.R.A.) –de la que me enorgullezco de ser miembro de honor— de los Congresos Patagónicos de Derecho Romano y de

los relativos a “Principios Generales” que, anualmente, organiza con gran brillantez, la Universidad bonaerense de Flores. En las sesiones científicas—y en los también imprescindibles actos sociales—pude colegir su honda preparación y exquisitez en el trato. Finalmente, pero no en último lugar, porque estas líneas prologales eran dedicadas a glosar una obra escrita tras largos años de dedicación al Derecho Romano; en efecto, un texto de exclusivo alcance pedagógico como el que glosamos, sólo puede ser confeccionado al socaire de largas y frecuentes reflexiones, lo que convierte a la manualística en una técnica únicamente accesible a aquellos que han alcanzado un alto grado de madurez profesional y, por ende, biológica. Yo siempre he desconfiado, en consecuencia, de aquellos libros de texto redactados a vuelapluma por autores inexpertos... Dicho lo cual, y a modo de conclusión de mi exordio inicial, debo decir aquí y ahora que el recién salido de la imprenta: *Ius Romanorum. Historia y Derecho del legado romano* representa, ante todo y sobre todo, un ejercicio de dominio académico sólo asumible por aquellos –muy pocos– que a su experiencia dilatada añan una *auctoritas* incontestable.

Estas lecciones fueron escritas para alumnos que inician sus estudios en Derecho y que deben ser conscientes desde el comienzo de su andadura por el proceloso campo jurídico de que la experiencia iusprivalista romana trasciende el período de tiempo imprescindible para conformar el pilar básico sobre el que se asienta el derecho privado europeo e iberoamericano. Llegados a este punto en nuestro iter expositivo, cabe preguntarnos qué sentido tiene una vez que el Derecho ha sido encerrado en los códigos, seguir enseñando y aprendiendo Derecho Romano en el tercer milenio. Y aquí retornamos forzosamente a la obra que prologamos: la calidad de un manual de una disciplina histórica depende de dos factores: su capacidad para incorporar los avances registrados en la investigación especializada y su inteligencia para interrogar al pasado sobre cuestiones que interesan al presente. Este libro de texto, así las cosas, se suma con acierto a la vasta corriente bibliográfica que reivindica con rotundidad las

enseñanzas del *Ius Romanum* en las Facultades de Derecho. El Derecho Romano es historia, pero por ser historia no puede declinar sus relaciones con el presente y su enlace con el porvenir: no es solamente un objeto de erudición, sino el elemento básico para el conocimiento del derecho privado de todos los países con cultura jurídica de progenie europea. Ante los nuevos horizontes de la unificación internacional del derecho privado, el Derecho Romano constituye la imprescindible base y reserva de concepciones y esquemas comunes de la jurisprudencia occidental. No es, pues, pura arqueología, sino parte viva del derecho moderno. En efecto, en relación con el derecho positivo, constituye el Derecho Romano un poderoso auxiliar interpretativo, ya que el Código no representa sino el punto histórico final en la evolución de un principio jurídico y sólo puede llegarse a una cabal comprensión del mismo analizando la raíz remota de donde proceda.

Y ya descendiendo a aspectos concretos del libro que nos ocupa, la A. muy atinadamente, ha optado por abrirlo clarificando el concepto de Derecho Romano y las diversas dicotomías de *ius*. Si—como hemos tenido ocasión de señalar— el Derecho Romano sirve, sobre todo, para introducir al alumno en los conceptos básicos del derecho privado, lógicamente no es posible dedicar un tiempo excesivo a esta introducción; pero ello no obsta en modo alguno para que se tenga sumo cuidado en que las primeras nociones —indispensables— queden bien explicadas. A nuestro juicio, se trata de un momento especialmente delicado en el que se está iniciando la necesaria compenetración entre el profesor y unos alumnos que acaban de entrar en la universidad y que carecen de un mínimo bagaje de conocimientos jurídicos. En segundo término, porque la profunda inserción del Derecho Romano en la realidad social —entendida en su acepción más amplia— exige una explicación del derecho privado romano en el marco de los fenómenos políticos, económicos y sociales de la época; explicación que—aunque somera en el tiempo por las razones de distribución del programa—debe servir para conferirle al alumno el

imprescindible bagaje de conocimientos acerca del derecho público romano del que —desgraciadamente— carece.

El libro se refiere en su mayor parte a las instituciones de derecho romano privado. Es obviamente la más extensa y, a la hora de estructurarla la autora ha optado por la clásica e inveterada orden expositiva en personas, cosas y acciones, la más genuinamente romana de Sabino y Gayo; en lugar de la propugnada por la pandectística que es la seguida en la mayoría de los tratados y manuales de Derecho Romano de progenie europea. Las instituciones se estructuran a su vez en diversos grandes apartados: Personas y Familia, Derecho Reales, Negocio Jurídico, Obligaciones y Contratos y se cierran con el Proceso. La Parte General, dedicada tanto a las personas tanto físicas como jurídicas y a la familia, constituye como una antesala del Derecho Hereditario y es tratada a modo de introducción del mismo ya que, como es sabido, la realidad familiar es analizada por la jurisprudencia sólo en su aspecto patrimonial y constituye al propio tiempo, el ámbito natural de la sucesión *mortis causa*. Por otra parte, se separan en el matrimonio los aspectos personales de los matrimoniales, dedicando un apartado específico a éstos últimos e incluyendo en el mismo, lógicamente, la dote y las donaciones *propter nuptias*. A esta misma sede se lleva también la tutela, en razón básicamente de su evidente desconexión con la familia, por cuanto, normalmente, es la desaparición del *pater familias* el hecho de que, de manera ordinaria, provoca la aparición de la institución, de ahí que —muy concretamente— la lección de tutela siga a la de *patria potestas*.

Me parece muy oportuna la exposición de los Derechos Reales antes de abordar la problemática relativa a las Obligaciones y Contratos, porque si el alumno conoce lo que es la propiedad o la posesión o el usufructo, por ejemplo, podrá calibrar mejor las múltiples posibilidades que ofrecen los modos de obligarse. La autora se inclina por la inserción de un capítulo dedicado al Negocio Jurídico. Es cierto, que los juristas no hicieron una exposición teórica independiente del negocio jurídico, sino que fueron señalando pautas —siguiendo el

método casuístico— principalmente al tratar de las obligaciones y, en cierta medida también, de las sucesiones. La doctrina del negocio jurídico es, pues, una elaboración abstracta de la pandectística, que procedió a sistematizar de un modo unitario las soluciones que los juristas romanos dieron a diversas instituciones, sobre todo en sede de contratos y testamentos, pero esta aparente fragmentariedad y sedes dispersas del tratamiento de lo que hoy llamamos negocio jurídico, no es tan disperso y caótico como a primera vista pudiera parecer; es evidente el tratamiento romano de figuras como condiciones, término, modo, causa, forma y donde hay conjuntos asociativos convergen siempre hacia conjuntos sistemáticos. Por consiguiente, habida cuenta de que son minoría los programas que hacen caso omiso del tema, la Profesora Aramburu, con buen criterio, ha optado por darle cabida en el libro a la categoría dogmática del negocio jurídico. El texto finaliza con el Derecho Procesal, ya que el derecho privado romano fue, en gran medida, un sistema de acciones, lo que implica una íntima conexión entre derecho procesal y derecho sustantivo.

A modo de resumen explicativo en punto a la orientación metodológica seguida por la A., soy plenamente consciente de que acometer la redacción de un libro de texto constituye una tarea muy delicada. Puede ser afrontada de modos diferentes. Cada uno tiene su justificación basada sobre todo en las cualidades docentes, en la formación cultural y mental de quien la escribe y en el ambiente a que se destina la obra. Pero, en todo caso, cabe destacar el esfuerzo de la Prof.^a Romina del Valle Aramburu por emplear intencionadamente un lenguaje simple, claro, pedagógico, en suma, que convierte al manual en útil en grado muy elevado a los alumnos quienes son a la postre los destinatarios del mismo.

El libro se estructura en diecinueve capítulos que comparten una obsesión común: la pedagogía y la claridad solidarias. La primera para conjugar el proverbio escolástico medieval de *gustibus et coloribus non est disputandum*: porque los gustos estéticos son modificables por el estudio, por la comprensión, por la cultura. La segunda

porque sólo la claridad transmite el pensamiento y lo ameniza. Y en este sentido la tarea de la A. es encomiable. Todos los apartados de su *Ius Romanorum* están sustentados por una impecable estructura lógica, fluyendo su discurso con inteligencia y orden expositivos. Un castellano irreprochable, severo, ceñido y rico constituye el vehículo de sus ideas a las que un ritmo y una coloratura especiales y a veces un lirismo hondo, dotan de fuerza persuasiva, desembocando sin solución de continuidad—cual torrente bien encauzado—en el derecho vivo y vigente. Esfuerzo casi baldío supone intentar resumir en pocas letras un compendio majestuoso de datos ordenados en una exposición muy bien sistematizada. A mí me resta felicitar a su autora públicamente—en privado ya lo hice cuando este libro salió de la imprenta—y felicitarnos de contar con su magisterio constante.

Prof. Dr. H. C. Luis Rodríguez Ennes
Catedrático Emérito de Derecho Romano
Universidad de Vigo (España)
R.R.A.A. de la Historia y de Jurisprudencia
Armenteira (España) 8 de enero de 2020

FRANCIA

Escribir sobre Roma y su derecho no es una tarea fácil, requiere conocimientos que es posible adquirir solamente con dedicación y esfuerzo, tarea en la doctora Romina del Valle Aramburu se ha especializado desde muy joven. Es por ello que esta obra resulta ser un producto del estudio realizado con dedicación y conocimientos demostrados a través de un examen minucioso de las instituciones históricas y jurídicas, desde el dramático período etrusco, pasando luego a través de un proceso único, sin precedentes, que ya era una realidad a fines del siglo III a. C. en el que la originalidad de su sistema político había ido estableciendo un derecho único e irrepetible en el Mundo Antiguo, contando con el concurso de un eficaz ejército que le permitieron ser una auténtica señora del “Mare Nostrum”, transformando “la ciudad” para convertirse en la gestora de un «orden romanus», que se fue multiplicando por toda Europa para llegar hasta los lejanos territorios de África y Asia, perdurando a través de los siglos. Sus instituciones fueron adoptadas y han permanecido vigentes más allá o por encima de los avatares de los tiempos.

La profesora Aramburu sigue perfectamente los vasos conductores que dan origen a las principales figuras jurídicas y muestran la evolución que cada uno de los derechos ha tenido desde sus orígenes, llegando a la culminación de los mismos, lo que explica en un perfecto orden sistemático en cada uno de sus capítulos, con total claridad y fácil acceso.

Esta obra aporta al derecho romano la originalidad de su exposición, generosamente perfilados y de simple acceso tanto para el neófito como para el especialista, ubicándola entre la más completa e importante en su género, permitiendo al lector descubrir guiños del pasado al presente, de forma tal que la más grande civilización de la historia nos permite entender. A través del pasado, las claves para el futuro, inspirando a cada individuo a ser protagonista de un derecho imprescriptible e ilimitado.

La Plata, Provincia de Buenos Aires 15 de enero del 2020.

FRANJA
MORASA

HECTOR EDUARDO LÁZZARO
Profesor extraordinario Consulto
Universidad Nacional de LaPlata

CAPÍTULO I

La Monarquía

I. Definición de Derecho Romano- *Ius Romanorum*

Es el conjunto de normas jurídicas creadoras de instituciones que rigieron la vida política, social y económica desde la conformación de Roma hasta el fin del imperio romano de oriente.

II. Clasificaciones

A) Derecho Público – *ius publicum*- y sus acepciones

Se refiere a las normas que regulan las relaciones jurídicas del Estado como tal. Se dirigen a establecer un orden social, político y económico de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado como gobierno y administración.

También se define como: la organización de la ciudad y las relaciones de ésta con los individuos.

Se puede referir a la cosa pública romana, o sea la que le pertenece al gobierno romano y la administra para sus ciudadanos, por ejem-

plo, las cosas sagradas, la *jurisdictio* de los magistrados. Están por encima de cualquier acuerdo que los particulares puedan realizar.

Del *ius publicum* pueden derivar:

El *ius suffragii*: Es una de las prerrogativas que tienen los ciudadanos romanos, es el derecho a formar parte de los comicios donde se vota ya sea para elegir a los magistrados, para sancionar las leyes y para la administración de justicia.

El *ius honorum*: Otra de las prerrogativas, se refiere al derecho a desempeñar magistraturas.

El *ius sacrorum et sacerdotum*: Es el derecho a desempeñar las magistraturas sagradas, poder a ser elegido para integrar los colegios sacerdotales de los pontífices, de los augures, de los auspices, de los feciales, etc.

B) Derecho Privado -*ius privatum*- y sus acepciones

Regula como tienen que funcionar las relaciones entre los sujetos, por ejemplo cuestiones de familia, del derecho sucesorio, contratos, por mencionar algunas.

Entre sus derivaciones encontramos: El *ius commercii* comprende el derecho a ser propietario conforme al derecho quiritario, realizar todos los actos o negocios jurídicos que permitan adquirir la propiedad civil. Lo poseen los ciudadanos romanos y en algunos casos los latinos.

El *ius connubii*: Derecho de celebrar las *iustae* nupcias o matrimonio civil romano, propia de los /as ciudadanos/as romanos. De allí derivaban todas las cuestiones relacionadas con el derecho de familia.

Lo que se conocía como *ius testamenti factio*: Era el derecho a instituir herederos (activa) y derecho a heredar a otro (pasiva). La tenían los latinos que gozaban del *ius commercii*.

El *ius provocatio ad populum*: Derecho de reclamar ante los comicios populares por la imposición de penas en los juicios criminales.

C) El fas

Era el derecho divino, sagrado o religioso o *lex divina*, en los primeros tiempos.

Para Celso, según Ulpiano *Ius est ars boni et aequi*, se va produciendo el predominio de la razón, del bien y de la equidad, como dogma del derecho que los jurisconsultos romanos van plasmando y que se ve en las Constituciones Imperiales, así Ulpiano decía que cultivamos la justicia, la ciencia del bien y de la equidad, separando lo justo de lo injusto, lo lícito de lo ilícito, haciendo buenos a los hombres no solo por el temor a las penas, sino por el deseo del premio, en lo cual consiste la verdadera filosofía”. Desde el punto de vista filosófico y de los juristas romanos el derecho es lo que siempre es bueno y equitativo en cuanto al conjunto de preceptos y de la doctrina, el arte de lo bueno y equitativo.

El *ius* luego se aplicó a todo el derecho, en su comienzo fue la voluntad de los dioses como creadora del derecho, luego cuando el derecho se hizo laico se extendió a toda norma jurídica.

D) Derecho Natural. Definición y acepciones

La Definición de Ulpiano acerca del derecho natural, dice lo siguiente”... el derecho natural es aquél que la naturaleza le enseña a todos los animales, ya que éste derecho no es propio del género humano, sino común a todos los animales que nacen en el cielo, en la tierra y en el mar”, Inst.I,2, pr; D.I,1,3.-

Son las normas que basan su razón de ser o su existencia en el hombre.

Ulpiano refirió que el derecho natural rige también la conducta de los animales, aquello que la naturaleza enseña a todos los animales.

III. El Derecho Natural en las Fuentes

- 1) Las Institutas de Justiniano: Este autor nos dice que el derecho natural es aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, no es privativo del género humano, sino de todos los animales.
- 2) Ulpiano: Considera al derecho natural como una fuente del derecho privado de una misma categoría que el derecho de gentes y el civil, ha sido crítica al sostener que la definición carece de utilidad práctica.
- 3) También se considera que el derecho natural debe buscarse en aquellos actos del hombre en los que actúa por impulso de la naturaleza como lo haría el animal: como la defensa propia, la unión de los sexos, la crianza y alimentación de los hijos, el ejercicio de la libertad. La noción de la independencia del derecho natural con el derecho de gentes y el civil habría sido introducido en Roma por Cicerón, sobre el derecho de distintos pueblos sostenían la existencia de una norma superior, la ley de la recta razón. Consideraba que había que ajustar la conducta humana a las exigencias de la naturaleza porque entendía que ella estaba gobernada por una ley eterna e inmutable que hacía que el individuo no pudiera sustraerse a la misma por ser inherente a su esencia humana.
- 4) El jurista Gaius: En su obra *Institutas* expresa que el derecho privado se forma por el derecho civil y de gentes o natural, definiendo al último como aquel que la razón natural establece entre los hombres. Estaba integrado por normas aplicables a todos los pueblos regidos por principios universales.
- 5) Paulo: Para éste jurista el derecho natural se refiere a lo equitativo y bueno.

E) El Ius Gentium

No era exclusivo del ciudadano romano. Las instituciones eran comunes a los diferentes pueblos y regía las relaciones jurídicas entre individuos miembros de diferentes comunidades.

Como el *jus Gentium* se funda en la razón, es llamado generalmente *jus naturale*, por los jurisconsultos romanos, pero no se le debe confundir con el *ius naturale* propiamente dicho ni con el derecho natural moderno. Este último, denominado también *filosofía del derecho*, es un ideal de la razón humana, en tanto que el *ius gentium* proviene del derecho positivo de las naciones civilizadas o por lo menos es considerado como tal.

Por otra parte, el *ius gentium* no debe confundirse con el derecho internacional, el cual reglamenta las relaciones entre los pueblos.

F) El derecho civil (*ius civile*)

Eran las reglas propias de los ciudadanos romanos, quedaban excluidos los extranjeros.

El derecho civil tuvo diversas fuentes, la costumbre, la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones imperiales y la respuesta de los prudentes, con el aporte realizado por la religión, las costumbres y las tradiciones romanas.

Cuando fueron muchos los extranjeros que vivían en Roma o se hizo necesario que hubiera un ordenamiento jurídico que los rigiera, ya sea por las relaciones entre ellos o con los ciudadanos romanos por ese motivo apareció la labor del pretor peregrino que ésta clase de vinculaciones jurídicas.

Cuando el derecho de gentes adquiere valor a causa de su campo de aplicación y a su carácter equitativo, gravitó sobre el derecho civil por conducto del pretor peregrino quien influyó en las decisiones del pretor urbano, basándose en la *aequitas*, hizo que el *ius civile* fuera perdiendo su primitiva preponderancia el edicto del magistrado, particularmente el pretor, empezó a llenar lagunas del derecho y a complementarlo ante dificultades interpretativas.

Tres son los juristas romanos que según los datos aportados por el *Corpus Iuris Civilis* trataron directamente el derecho natural: Gayo (s II d.C.), Ulpiano (muerto el 228 d. C.) y Paulo (s III d.C.).

a) En las Institutas de Gayo: encontramos como primera clasificación la que distingue el *ius civile* del *ius gentium*, según se observa: “Todos los pueblos que se rigen por ley y la costumbre usan en parte su propio derecho, y en parte el derecho común de todos los hombres; pues el derecho que cada pueblo establece para sí, ése es suyo propio, y se llama derecho civil, como si dijéramos derecho propio de la ciudad; en cambio, el que la razón natural establece entre todos los hombres, ése se observa uniformemente entre todos los pueblos se llama derecho de gentes, como si dijéramos el derecho que usan todas las naciones.

Así, pues el pueblo romano usa en parte de su propio derecho, y en parte del derecho común de todos los hombres. Del examen de este pasaje de Gayo, que lleva por título *De jure civili et naturali* (Del derecho civil y del derecho natural), se desprende que la oposición que nos presenta este jurista es la que se establece entre el *jus civile* y el *jus gentium*. Pero como solamente nos habla de este último en el encabezamiento de dicho pasaje, resulta que para Gayo no hay otra manifestación del derecho objetivo que el derecho civil y el derecho de gentes, identificándosele este último con el derecho natural.

Se funda al derecho de gentes en la razón natural cuando se dice, *quod naturalis ratio inter omnes homines constituit... vocatuque ius gentium*, dicho de otra manera el que la *razón natural* establece entre todos los hombres, se llama derecho de gentes.

Lo propio resulta de otro texto de la jurisprudencia clásica que ha llegado directamente hasta nosotros formando parte del *Fragmento Dositeano* pasaje de jurisprudencia de autor desconocido y llamado de ese modo por figurar en un manuscrito como apéndice del *Ars Gramática* de Dositeo. En efecto, lo mismo que encontramos en Gayo, se divide al derecho en civil y de gentes, el último de los cuales es asimilado al derecho natural, según se desprende de la parte en que se dice: . . . *naturale dicitur etiam ius gentium* (...el natural, que se llama también derecho de gentes).

Gayo entiende por derecho civil el *ius proprium civitatis*, o sea el derecho propio de la ciudad, y cuando a la expresión *iure civile* se le

agrega *romanorum*, se refiere al derecho propio de los ciudadanos romanos. Es el derecho que la ciudad establece por sus órganos competentes y cuyos titulares son, los *cives*, es decir, quienes forman parte de la ciudad.

b) El Jurista Paulo

También encontramos en él la distinción entre *ius civile* y *ius naturale*, la palabra derecho se emplea en varias acepciones: una, cuando se llama derecho a lo que siempre es justo y bueno, como el derecho natural, otra acepción es lo que en cada ciudad es útil para todos o para muchos, como el derecho civil. Es de destacar que el derecho natural, por fundarse en la naturaleza de las cosas, es siempre justo y bueno; el derecho positivo, en cambio, se basa en la utilidad y por eso es variable.

c) Ulpiano

Manifiesta que el derecho privado es tripartito, pues está compuesto por preceptos naturales, de gentes y civiles. Es derecho natural aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es sólo propio del género humano, sino común a todos los animales de la tierra y el mar, también es común a las aves. De ahí deriva la unión del macho y de la hembra que nosotros llamamos matrimonio, de ahí la procreación de los hijos y de ahí su educación. Pues vemos que también los animales, incluso los salvajes, parecen tener conocimiento de este derecho. Es derecho de gentes aquel que usan todos los pueblos humanos. Es derecho civil el que no se aparta en todo del natural o de gentes, ni se conforma totalmente a él. Así, pues, cuando añadimos o sustraemos algo al derecho común, lo hacemos derecho propio, es decir civil. Y este derecho nuestro es en parte escrito y en parte no escrito.

Así manifiesta que:

El derecho natural es aquel que la naturaleza inspira a todos los animales. Este no es especial del linaje humano, sino común a todos

los animales en el cielo, en la tierra y en el mar. De aquí procede la unión del varón y de la hembra, que llamamos matrimonio; de aquí la procreación y educación de los hijos. Vemos, en efecto, a los demás animales, que se conforman a los principios de este derecho como si lo conociesen - Justiniani; Institutas; I, 2-

Este pasaje de Justiniano se repite en términos casi idénticos en otro fragmento del Digesto I, 19, 29, se atribuye a Ulpiano la afirmación que sigue:

El derecho privado consta de tres partes, pues está compuesto de los preceptos naturales, o de los de gentes, o de los civiles... Derecho natural es aquel que la naturaleza enseña a todos los animales, pues este derecho no es peculiar del género humano, sino común a todos los animales que nacen en la tierra o en el mar, y también a las aves.

Ahora bien, ¿cómo explicar la aparente contradicción que existiría entre lo que afirman los juristas clásicos y lo que enseñan las Institutas de Justiniano, y Ulpiano en el Digesto, por qué esos juristas clásicos, especialmente Gayo en sus Institutas, no hacen más que una bipartición entre el *ius civile* y el *ius gentium*, el último de los cuales se equipararía al *ius naturale*.

Pero Ulpiano nos habla del *ius naturale* y del *ius gentium* como de dos conceptos distintos. De acuerdo con su doctrina, habría un *ius civile*, cuyo sujeto sería el ciudadano, es decir, el miembro de una determinada colectividad; habría, además, un *ius gentium*, cuyo sujeto sería el hombre como tal, prescindiendo de que forme parte o no de una colectividad determinada; habría, por último, un *ius naturale*, cuyo sujeto serían todos los seres vivos, indistintamente hombres y animales.

Claro está que una interpretación tan amplia del *ius naturale* ha debido causar sorpresa a muchos intérpretes del derecho romano, quienes se resisten a admitir que entre los animales puedan darse instituciones jurídicas, o que puedan existir normas jurídicas comunes a

hombres y animales. Podrá existir identidad de necesidades biológicas, de instintos, pero nunca comunidad de derecho, como lo habría reconocido el mismo Ulpiano en D. X,1,1,03. Por lo que esos intérpretes llegan a afirmar que los textos que la compilación justiniana atribuye a Ulpiano han sido interpolados, es decir, que no serían genuinos.

En otros textos del Digesto, en que también se refiere al *ius naturale*, tampoco corresponderían a los juristas clásicos, sino que serían el resultado de interpolaciones realizadas por los compiladores. Se refiere especialmente a un pasaje atribuido a Paulo, quien según los compiladores Dig., Lib. 1, tit. Iº, fr. 11, habría definido así al derecho natural en el Libro XIV de los “Comentarios a Sabino”: “Dícese derecho en varias acepciones. En una, cuando se llama derecho a lo que es siempre equitativo y bueno, como es el derecho natural...”. De acuerdo con esto, el *ius naturale* es el que se apoya en razones superiores e inmanentes de Justicia. Se identifica con la justicia.

No hay que confundir el *ius gentium* con el *ius naturale* si se tiene en cuenta que existen instituciones admitidas por el *ius gentium* que serían rechazadas por el *ius naturale*.

El *ius gentium* estaría integrado por todas aquellas instituciones comunes al derecho de todos los pueblos.

G) El *ius scriptum* y *ius non scriptum*

- a. El *ius non scriptum* está representado por la *mos maiorum*, la costumbre de los antepasados, que corresponden a la primera etapa de la evolución del derecho romano.
- b. El *ius scriptum*, por oposición al anterior, es el que deriva de las otras fuentes productoras del derecho:
 - 1º) la *lex*;
 - 2º) los plebiscitos;
 - 3º) los *senatus consultus*;
 - 4) las constituciones imperiales;
 - 5) las respuestas de los prudentes; y

6) los edictos de los magistrados que tienen el *ius edicendi*, o sea el derecho de publicarlos, como el pretor urbano, el pretor peregrino y el edil curul; estos edictos dieron origen al llamado derecho honorario.

H) La *Iustitia*: Concepto

Es el arte de lo bueno y de lo equitativo, concepto dado por Celso, en D.I, 1.

El Jurisconsulto es llamado sacerdote pues cultivamos la justicia... separando lo justo de lo injusto discerniendo lo lícito de lo ilícito, deseando hacer buenos a los hombres, no solo por el miedo a las penas...” D.I,1,1.

También se define como: la voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le pertenece D,I,1,10.

Repeler la injuria D.I,1,3, es propio del derecho de gentes, la razón natural les mueve a rechazarla.

La manumisión tuvo su origen en el derecho de gentes, quiere decir dejar de la mano bajo la cual otro es esclavo D.I,1,4, solo por dar algunos ejemplos.

Los principios del derecho son, los Preceptos Fundamentales de Ulpiano:

Dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a los demás D.I,1,10.

- Vivir como se debe, se refiere que debemos proceder de manera tal que no haya personas perjudicadas de manera individual o socialmente no realizando aquello que está prohibido.
- No hacer daño a otro, significa que no debemos perjudicar a otros por medio de robos, violencias y otras cuestiones, como nosotros no quisiéramos que terceros lo hicieran en contra nuestro. Los preceptos se refieren a la patria a los individuos, y a las demás personas con las que tiene que convivir socialmente.

- Es el fundamento de muchas leyes civiles y todas las leyes penales, la prohibición de la ley es inexcusable que se invoque como garantía de los derechos de los demás.
- Dar a cada uno lo suyo: Éste precepto responde al bien común de la República y de la sociedad, por un lado tenemos a los gobernantes que buscan el bien común, tiene que haber un equilibrio entre los derechos de todos, el que ha lesionado un derecho tiene obligación de repararlo y aquellos que transgreden las normas son castigados con la aplicación de una pena, el trabajo y la virtud son premiados.

Para que un acto se ajustó no solo tiene que estar acorde con el derecho, sino que tiene que existir la voluntad en los sujetos de práctica como acciones de la vida la justicia, el desinterés en práctica el bien hace morales a las acciones humanas, por eso se la consideraba a la justicia desde el punto de vista moral de allí surge la definición que se dio.

I) Jurisprudencia

Es conocimiento de las cosas divinas y humanas, y ciencia de lo justo y de lo injusto - D.I,1,10-. Enseña el modo práctico en que se aplican las reglas establecidas por la justicia. Dicho de otra manera jurisprudencia es la filosofía de lo justo y de lo injusto, no consiste solamente en el conocimiento de las leyes, de la costumbre y usos, sino que es el conocimiento de todas las cosas divinas y humanas a las que se les aplican reglas de lo justo. Las cosas divinas constituían para los romanos una rama importante de la jurisprudencia, por la estrecha relación entre el Estado y la religión.

J) La Costumbre

Si hay leyes escritas deben respetarse éstas, pero si no las hay se debe seguir lo establecido por los usos y las costumbres, si se diera el caso de que éstas no existieran se debe seguir lo más aproximado a la las leyes como la costumbre surgen del consentimiento del *populus* “*en aquellas causas que no usamos leyes escritas conviene Que se guarde aquello introducido por el uso y la costumbre...*” D.I,3,32.

A. Derogación de las Leyes

Era válida por la derogación de una norma jurídica por la imposición de las transformaciones sociales, y os cambios de conductas de los miembros dela comunidad,

“Es legítimo que se deroguen las leyes, no solo por la voluntad del legislador, sino también por el no uso por tácito consentimiento de todos”- D.I,3,32,

La costumbre puede estar acorde a la ley o ser contraria a ella, en éste último caso deroga a la norma escrita, pero cualquier acto que los individuos realicen no se van a convertir en costumbre sino aquella que dure varias generaciones, que sea practicada por la mayoría de los individuos que componen la sociedad y no solo por algunos de ellos.

La costumbre inveterada suele observarse por derecho y ley en aquellas cosas que no provienen del derecho escrito, D.I.3.33.

B. La costumbre para ser invocada ante los tribunales

Cuando la costumbre que es contraria a la ley está establecida como tal se debe a los primeros transgresores que la han instaurado, sino a todos aquellos que, en el tiempo, la han continuado de buena fe, puede opinarse como que no es costumbre en el sentido que se está analizando, se trata de una transgresión de la ley.

Cuando alguno se funda en la costumbre de la ciudad, juzgo que primero se ha de mirar si ésta costumbre ha sido alguna vez confirmada en juicio contradictorio D.I,3,34

Puede ocurrir que ante una determinada situación en la que se alegue la costumbre y por otro lado se alegue el derecho, se lo tendrá como costumbre cuando se demuestre que en juicio ha sido probado como tal.

La práctica de la costumbre es aceptada por lo general por todos sin generar mayores dificultades, con igual valor que la norma escrita.

C. Fuerza de la Costumbre

La fuerza de la costumbre proviene de su autoridad, de su propia creación, por eso no fue necesario plasmarla por escrito, ello significa que la importancia de la instauración de la costumbre hizo que no sea necesaria plasmarla por escrito para que ella tuviera autoridad por sí misma.

En caso de que hubiera dudas acerca de la interpretación de la ley, ya se establecía tener en cuenta el derecho la ciudad de Roma que se había aplicado antes a otros casos similares, porque la costumbre era tenida como la mejor intérprete de las normas.

D. Disposición de Severo en relación a la costumbre

Severo ordeno por rescripto que la costumbre o autoridad de las cosas juzgadas perpetuamente de una misma manera, debía tener fuerza de ley en las dudas que se ofrecen en las leyes.

Todo derecho fue establecido por el consentimiento, por la necesidad o le dio fuerza la costumbre, la ley surge por el consentimiento y la voluntad, por necesidad es cuando el senado lo estatuye por delegación del *populus*, la costumbre tiene en sí misma fuerza de ley por el extenso tiempo en que se llevan a cabo, allí se ve claro el consentimiento del pueblo que no se había hecho por escrito, se trata de un consentimiento tácito.

K) Las Constituciones imperiales

Epístola o consulta se llaman las consultas que los jueces hacen de sus sentencias o de causas que ellos deben resolver (las sentencias son confirmadas por el príncipe o consejo) y se pueden apelar.

Todo lo que el Emperador estableció por carta, subscripción o decreto, con conocimiento de causa o por sentencia interlocutoria, sin figura de juicio o mandó por edicto, son llamadas constituciones.

L) Decretos

Son los que el príncipe pronuncia con conocimiento de causa, mientras que los rescriptos se dictan sin conocimiento de causa. La sentencia interlocutoria tiene carácter de definitiva y por supuesto con fuerza de ley. Algunas constituciones son personales porque están dirigidas a determinadas personas y otras son de carácter general porque los Príncipes tienen la facultad de crear privilegios o dictar leyes de carácter general.

M) Función del derecho pretorio:

Cuando finalizó la intervención de los redactores de las XII Tablas, también lo hizo la intervención de los magistrados, tampoco se designaba a un miembro del Colegio de los Pontífices para que interviniera en las causas de los particulares, entonces quién cumpliría la función era el magistrado llamado Pretor, que publicaba edictos con el fin de suprimir, corregir o modificar el derecho civil, eran los Edictos¹ Pretorios, también estaban los edictos de los ediles. El primer pretor se nombró en el año 387. Después de la muerte de Rómulo se designaron diez varones cada uno al frente de cada una de las diez curias, en el año 302 se eligieron otros diez, de cada tribu se elegían tres para que decidan en las causas, así surge el número de ciento cinco, que pasó a denominarse el tribunal de los centunviro- *Centum Vires*- si bien no eran magistrados tenían amplia jurisdicción, luego formaron cuatro tribunales presidida por el Pretor. El Pretor duraba en su función un año y ese era el plazo de duración de la normativa que dictaban.

N) El dictador

Al Senado se le dificultaba la administración de todas la provincias entonces surgió la necesidad de designar a un Príncipe se le dio la

1 Se escribían en tablas de madera o en paredes blanqueadas donde estaba el edificio del Pretor.

facultad de que todo cuanto determinase se tuviera por firme y válido”. A éste Príncipe se lo denominó Dictador (el origen de su nombre estaba dado en que tenía libertad para dictar lo que correspondía), duraba en su cargos seis meses, paralelamente había cónsules y los magistrados que había en tiempos de la República, designándose otros magistrados menores y otros magistrados para el gobierno de las provincias. Las sentencias de los cónsules se apelaban ante el dictador, ya que era un magistrado extraordinario. Era elegido por el pueblo.

No todos los magistrados eran jurisconsultos, entonces cuando surgían dudas de derecho, se les designaban jurisperitos.

El Dictador tenía plena potestad para condenar a pena capital a un ciudadano romano, las sentencias no se apelaban.

O) El *Tribunum Celerum*

Era un capitán del cuerpo de guardia, mandaba a los caballeros y era el segundo del Rey, el primero fue Junio Bruto. Al principio Rómulo creó el orden equestre de 300 caballeros llamados *celeres*, al comandante se lo llamó Tribuno Celerum, así nacían los primeros tribunos. Los Celeres estaban divididos en tres cuerpos que tenían diferentes nombres:

- a) Tacienses, de Tacio fue el General de los Sabinos desde que habían hecho la paz con éstos (después de haber estado en guerra por el rapto de las sabinas, con el paso del tiempo hicieron la paz), estuvo en Roma y reinó cuatro años con Rómulo.
- b) Los Rumnenses
- c) Los Luceres de Luceria, pueblo de Etruria.

Dar a cada uno lo que le pertenece es una virtud moral, ya que se da un castigo a los que se merecen una pena, esto en relación con el concepto de *justitia*.

P) El senadoconsulto o constitución del senado

Cando se produjo un crecimiento de la población, se dificultó la acción de realizar las asambleas populares para que el pueblo diera su consentimiento, entonces fue el Senado el que tomaba decisiones, así aparecieron los senadoconsultos. En tiempos de la monarquía, había cien albanos y después fueron incorporados cien sabinos más. Las constituciones se podían dar de dos maneras: por voto o por aprobación de todos los senadores, en tiempos de Augusto el número de senadores aumenta a cuatrocientos debían asistir por lo menos la tercera parte. El lugar donde se reunían era consagrado por los Agoreros. Había dos especies de senados: uno se denominaba Legítimo: era el que tenía el día señalado por las calendas, Augusto determino que solo se podían tener dos senados legítimos por mes, que fueron las calendas y los idus, no había actividad del senado los meses de septiembre y de octubre y el otro *Indicto*, denominados de ésta manera porque no tenían día señalado, si se llevaba a cabo la reunión del senado pero no se cumplían algunos de los requisitos señalados los Tribunos de la Plebe que podían concurrir lo impugnaban y se declaraba írrito lo resuelto.

Si bien al principio los poderes del Senado eran amplios, ya que podían crear magistrados, dictar leyes, declarar la paz o la guerra luego se establecieron límites por la Ley Valeria.

No hay dudas que el senado puede establecer leyes, se refería a la fuerza de ley que tenían los senadoconsultos, hay que recordar que ésta potestad primero la tuvo el *populus* luego por la cantidad de gente que debía reunirse se hizo difícil hacerlo en la práctica y se delegó la facultad en el *senatus*.

Q) Las Curias

Rómulo dividió al pueblo en treinta partes que se llamaron curias.

Con la sublevación de los plebeyos en el Monte Sacro se crearon los magistrados plebeyos que eran los tribunos de la plebe, para contrarrestar a los cónsules ya que ésta ida al monte Sacro era una

rebelión también contra éstos. Para que regresaran nuevamente a la ciudad se negoció la aceptación de sus dos Tribunos, además de sancionar las Leyes Agrarias para la distribución de las tierras, la aceptación de los Tribunos era para poner fin a los insultos y otras faltas de respeto a la plebe, su función era defenderlos, también asistían al senado y cuando dictaban alguna constitución que perjudicaba los intereses de la plebe la intercedían o la declaraban írrita.

Mientras la plebe se encontraba en el Monte Sacro, dejaron en la ciudad dos personas que cuidaban de sus estatutos, así surgieron los Ediles.

R) Los Cuestores

A los fines de recaudar y guardar el dinero para el erario público se designaron a aquellos que se harían cargo, siendo los *quaestores erarii*, que significa Tesorero, se diferenciaban de los Tribunos del Erario que les entregaban los estipendios que les correspondían a las tropas. Cuando se trató el tema de los cónsules, se hizo referencia al *quaestor parricidii*. Eran jueces pesquisidores que tenían a su cargo la investigación de todos los delitos, siendo el parricidio lo más común en esa época de allí surge la denominación que tuvieron.

La Ley era para Demóstenes la conveniencia de los ciudadanos para cumplir, un don de Dios y un freno y castigo para los delitos cometidos voluntaria e involuntariamente.

S) Criterios para dividir la Historia del Derecho Romano

- 1) Comprende desde la Fundación de Roma hasta la *Lex* de las XII Tablas (año 750 a 450 a.C.), la fuente del derecho que encontramos en ésta época es la *mores maiorum*.
- 2) Desde la Ley de las XII Tablas hasta Cicerón (450 a 100 a.C.), época en la que Roma extiende sus territorios, se regía por el derecho civil y por el derecho honorario, aparecen los plebiscitos como consecuencia de las diferencias sociales entre patricios y plebeyos.

- 3) Época que abarca desde Cicerón hasta Alejandro Severo (100 a 250 d. J.) El Imperio ha tomado vastas dimensiones, se concede la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio.
- 4) Desde Alejandro Severo hasta Justiniano (250 a 550 d. J.) se utiliza como fuente del derecho las citas de los antiguos jurisconsultos y las Constituciones Imperiales.

Otra periodización puede ser la siguiente:

- a) Desde la fundación de Roma hasta la Ley de las XII Tablas;
- b) Desde la Ley de las XII Tablas hasta el Imperio;
- c) Desde el Imperio hasta Diocleciano;
- d) Desde Diocleciano hasta Justiniano.

T) Los juristas romanos y los juristas posteriores

A) Análisis acerca de si el jurista puede plantearse paradigmas

Se tratarán de abarcar distintos aspectos, cuál es la evolución histórica que ha sufrido éste papel dado que solo así podremos entender en el estado en el que nos encontramos actualmente.

Se intentará dar una acepción de la palabra jurista, dada la ambigüedad de la misma que puede ser objeto de más de una definición, no se pretende definirlo rígidamente sino que se brindarán algunas nociones y características de ésta.

La labor del jurista sería muy infértil si no fuera acompañada como complemento de la tarea legislativa, y que ésta a su vez, según entiendo no tendría sentido si no tiene como fuente de inspiración al jurista.

B) ¿Qué entendemos por jurista?

El jurista no es el simple abogado, sino es aquél que estudia con profundidad un área específica del derecho, del cual participa en su tiempo y trata de introducir innovaciones en la vorágine del cambio jurídico. Para ello deberá reunir determinados caracteres: ser comprensivo, estudioso, objetivo, consciente de la función social que cumple, promover las innovaciones, proponer el cambio, así se convierte en un

creador del derecho como el pretor, adaptándose a los nuevos conflictos que surgen por las evoluciones sociales normales, solo que no gozará de *imperium*, que el pueblo delega en sus legisladores.

Se puede afirmar que, el rol del abogado o del jurista como un oficio o un arte pero jurídico.

C) Breve evolución histórica

Dado que nuestro derecho nacional es de base netamente romanista pese a la evolución sufrida después por la influencia de los romanistas europeos principalmente de Von Savigny; Ihering, Saleilles; luego el derecho indiano o colonial con la influencia del derecho español, hasta la transición operada del derecho como la conocemos en nuestros días.

a) La Labor de los juristas de romanos

Para hacer referencia a los juristas no podemos dejar de desconocer la labor de los juristas romanos²; y su importancia, ya que a Roma era uno de los pueblos más adelantados de su época³ junto con los griegos; y que si bien a diferencia del hombre griego, que era sumamente culto e instruido, amante de la cultura que posteriormente nos legaron; el hombre romano era netamente guerrero a la vez que agricultor, sabía desempeñar bien los dos papeles para los cuáles era preparado y condicionado por la sociedad de su época, sin embargo es llamativo como han creado, estudiado, aplicado y modificado el derecho con el transcurso del tiempo.

La labor de éstos fue muy importante durante la época clásica, entre los más destacados nos encontramos con Papiniano, Capítón,

2 Por ejemplo en tiempos de Augusto fue muy importante la labor de los juristas, durante el principado los emperadores se rodearon de los hombres más prestigiosos de su época, en éste período se caracterizó la actuación por la evacuación de consultas que les hacían.

3 Desde tiempos remotos, se perfilaba la labor del jurista que era por entonces desempeñada por los pontífices, con la influencia de la religión.

Sabino, Próculo, Labeón, Pomponio, Gayo, Marcelo, Scaevola, Modestino, Ulpiano, Prisco, Juliano, Paulo.

Los juristas clásicos, que son los que han actuado desde Servio Sulpicio Rufo que vivió en el siglo I a.C hasta Modestino, en la primera parte del siglo III de la era cristiana. A ellos corresponde la labor más importante que se haya llevado a cabo en el Imperio Romano de elaboración de reglas, cuyo conjunto se denominó *iura* y que Justiniano compiló en su *Digesto*. La tarea de los Juristas se centró sobre tres aspectos básicos que fueron: a) el derecho civil, que estuvo constituido por los comentarios a la obras de Masurio Sabino, b) el derecho honorario, constituido por los comentarios al edicto perpetuo de Salvio Juliano, y c) las obras de jurisprudencia práctica que tuvieron como base las respuestas de Papiniano. Aparecen también obras de carácter didáctico y simple de tipo de las Instituciones de Gayo, destinadas a enseñar el derecho en sus primeros elementos.-

Las respuestas de los Jurisconsultos fueron definidas por Gayo como las sentencias y opiniones de los que estaban facultados para crear normas jurídicas. Los juristas intervenían en la producción del derecho mediante sus respuestas o responsas que podían ser de dos clases: a) se llamaban sentencias cuando existe unanimidad; b) en cambio reciben el nombre de opiniones cuando son establecidas por la mayoría de los juristas, no por todos. En la época imperial los juristas pierden el importante papel que habían desempeñado durante la república. Los mejores juristas fueron incorporados al Estado e ingresaron en el consejo imperial o en las secretarías imperiales, de modo que su labor va a orientarse a preparar los senados consultos o a preparar las constituciones imperiales. Mientras tanto, el campo de acción de los juristas particulares se ve limitado de dos maneras: en primer lugar por la intervención estatal y en segundo lugar, por la pérdida del importante papel que desempeñaban en la confección de los edictos de los magistrados a raíz de la codificación del derecho honorario.-

En época de Augustos se concedió a ciertos juristas el *Ius Publice Respondendi*, es decir, el derecho de emitir opinión como si fuese en nombre del emperador. Estos dictámenes tenían fuerza vinculante, como si se tratase de leyes, ya que obligaban al juez a fallar conforme los mismos. En el fondo era una restricción puesta a la jurisprudencia que se había desenvuelto durante la república sin contralor oficial.

b) Reseña del jurista en Argentina

Los juristas de nuestro país en cualquier época a la que han pertenecido, su labor se han destacado, como una particularidad por su participación en la política de nuestro país en la que tuvieron un importante rol.

Así nos encontramos con el Doctor Juan Bautista Alberdi, quién con su obra *Bases y Partidas para la Organización Política de la República Argentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización en la América del Sur*, sirvió de fuente inspiradora para los congresales que para 1852 año que corría dictarían en breve la Carta Magna de la Nación.

Cuando finalizó sus estudios de jurisprudencia en Buenos Aires, se niega a prestar el juramento que Rosas quería imponer a los egresados de la Universidad, “bajo pena de nulidad del título”, considerado denigrante por el novel abogado. Se exilia a Montevideo y luego a Europa hasta que se radica definitivamente en Valparaíso. Ejerció la profesión de abogado. Se interesó por conocer la realidad que los atravesaba en ese momento, es por eso que a su obra fundamental pretende adaptarla a la realidad del país, por lo que se puede decir que Alberdi fue un verdadero paradigmático, considerando que el hombre tenía que moldear el derecho que lo regiría o la forma de gobierno según los caracteres propios del suelo y de la población, teniendo en cuenta que algunos de nuestros representantes próceres se formaron como abogados en Europa, y las leyes tienen que nacer del seno mismo de las sociedades.

Otro destacado jurista que encontramos en nuestro país es el Doctor Rodolfo Rivarola, abogado, jurista como se dijo, y magistrado, en su actividad el mismo señalaba la importancia de pensar en las cosas del interés público, como un deber elemental de todo ciudadano, con sinceridad e independencia siendo consecuente con lo que se piensa. Nunca fue partidario de escuela o doctrina alguna, enseñó filosofía durante muchos años, fue expositor de doctrina o redactor de códigos, pudo demostrar que el hecho de adherirse a las doctrinas que por entonces estaban en boga, no lo hizo perder la visión de lo que sucedía en el país, también como muchos visionarios anteriores y posteriores, consideró que el hecho positivo social, debía mantenerse en el orden jurídico existente, basado en ideas y tradiciones destinados a transformarse por la evolución.

c) El Jurista en el derecho comparado

Así como la mayoría de los países europeos y americanos han tomado como base para la conformación de sus legislaciones locales el derecho romano, aún en los países más insólitos, por ejemplo, Rusia, Inglaterra, con un derecho muy distinto al nuestro, se han encontrado destacados juristas, entre ellos Ihering, que vio la necesidad de la consolidación de un sistema legislativo, por el caos existente con todas las desventajas que ello implica, la avidez de considerar al derecho romano como uno de los modelos fundamentales de su obra, que no ha sido tenido en cuenta por muchos de sus contemporáneos, las ideas de éste jurista expuestas en 1877 la importancia de la defensa de los derechos individuales como la mejor escuela para la lucha de los derechos de la colectividad. Es muy difícil pensar que los cambios jurídicos sean impuestos por el legislador con el uso de la fuerza y en contra de la idiosincrasia de una nación determinada en un momento dado, siendo lo contrario a la vez un modo de garantizar la efectividad de la tarea emprendida.

U) estudio del Derecho Romano en nuestro país

Como buen sabemos es una de la materias principales en la carrera de abogacía de las diversas universidades públicas y privadas al tener en nuestro país un derecho civilista de neta base romanista.

En la Universidad de Buenos Aires, Alberdi en una carta dirigida a Lucas González (un argentino que estaba estudiando derecho en la Universidad de Turín) manifiesta la importancia del estudio del derecho romano y del derecho canónico, ya que decía que el derecho romano es lo que se veía plasmado en las Leyes de las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio normativa que regía en esa época.

En 1863 se empezó a estudiar Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires estaba en primero y segundo año de la carrera de abogacía. Se siguió para su estudio la obra de Ortolán porque utilizaba el método histórico seguido por los franceses, en 1872 se produce una nueva corriente que se aleja de la de Ortolán, ésta es la de la corriente histórica como exponente en Argentina encontramos a López en el que criticaba el plan de las Institutas, estableciendo como fundamento del derecho civil a los contratos.

En el año 1874 apareció como Profesor el Dr. Pedro Goyena utilizó el método dogmático de interpretación, en el año 1888 la materia se dividía en 48 bolillas, se dividía el dictado en dos cursos.

Luego el Doctor Raimundo Wilmart adhiere al empleo de los métodos de la escuela evolucionista.

El Doctor Osvaldo Magnasco, planteó la supresión del curso de Historia del Derecho Romano porque no se encontraba en el plan de estudios de la Facultad, sin embargo en la práctica ese contenido se siguió dictando, se priorizaron el estudio de las fuentes del Derecho Romano, en especial a los edictos de los pretores.

En 1900 la cátedra estaba a cargo del Doctor Enrique Obarrio, la parte histórica se dividía en cuatro unidades Obarrio. Hasta 1933 el Derecho Romano se estudiaba en dos cursos. En el primero se estu-

diaba la parte histórica, derecho de familia y propiedad. En el segundo curso: Las obligaciones y las acciones.

En nuestro país el Código Civil Argentino o código de Vélez Sarsfield ha mantenido en sus instituciones la influencia del derecho romano, por ejemplo en tutela y curatela, posesión, propiedad y derechos reales en general, contratos y el derecho hereditario. Si bien al código originario se le añadieron transformaciones con la sanción de la Ley 17.711/68 no perdió esa esencia romana que tenía desde sus orígenes.

En la actualidad, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina creado por la Ley 26.994 Publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre de 2014, con entrada en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, en ésta normativa se han fusionado los anteriores códigos civil y de comercio han aparecido algunos institutos jurídicos novedosos que se han adaptado a las transformaciones sociales, políticas y económicas de Argentina, pero se mantiene en algunas figuras jurídicas parte de la raigambre de Vélez Sarsfield.

La monarquía: Orígenes. Leyenda y sus críticas

I. La fundación de Roma

A) Primera versión

Los orígenes de la monarquía se relacionan con Eneas, que descendía de Venus y Marte, luego de que los griegos incendiaran Troya huyó de allí, y llegó hasta Cartago. Finalmente llegó al Lacio y allí conoció a Lavinia con quién se casó por segunda vez, sin embargo éste hecho lo hizo caer en adulterio ya que Eneas estaba casado en Troya con Creusa y de esa unión había nacido Ascanio, había perdido a su esposa cuando escapó de los griegos.

Uno de los hijos que tuvo con su segunda esposa, fue el rey Procas, que tuvo a su vez dos hijos: Numitor el mayor, y Amulio, el menor, éste destronó al primero. La hija de Numitor Rea Silvia fue enviada al Colegio de las Vestales, para evitar así la posibilidad de que continuara la línea sucesoria de Numitor, sin embargo Baco la sedujo y de esa unión nacieron los mellizos Rómulo y Remo. Cuando Amulio se enteró de esto ordenó que los recién nacidos fueran arrojados en

una cesta al Tíber, tuvieron la suerte de llegar a las orillas y fueron recogidos por una mujer que los amantó y crió llamada Germal a la que le decían “La Loba”.

Cuando crecieron supieron de su ascendencia aristocrática y quisieron restituir el trono a su abuelo Numitor, no solo lograron su objetivo sino que fundaron una ciudad a orillas del río Tíber, de donde habían sido recogidos, así tomaron una porción de tierra de su ciudad natal Alba Longa, como acto fundacional, Rómulo trazó con un arado el perímetro en el que se iban a construir las murallas y las puertas de la ciudad. Remo saltó por decisión propia saltó el límite trazado por el arado y por tratarse de un lugar santo Rómulo le dio muerte para evitar que la ira de los dioses hicieran recaer sobre todos la desgracia, ya que ningún acto podía hacerse sin la influencia de los dioses, y si se quería realizar algo se debía consultarles, caso contrario la violación de los preceptos religión traería consecuencias negativas para quien lesionara ese orden.

Luego Rómulo quedó como primer rey de Roma.

B) Segunda versión de la Fundación

La leyenda de la fundación de Roma

Rhea, hija de Numitor de origen latino ambos, era una virgen vestal, que tuvo dos niños: Rómulo y Remo. Éstos fueron arrojados a una laguna y fueron recogidos por Fástulo, que a su vez se lo dio a una mujer llamada Laurencia. Era una mujer que no cumplía con sus deberes maritales con su marido pero sí con otros hombres por eso se la llamaba “la loba”. Del nombre de esta mujer se derivaría la palabra lupanar como el lugar en dónde se pueden encontrar a éstas mujeres que son de vida liviana, por decirlo de alguna manera.

Con el paso del tiempo se descubrió que los niños, eran nietos de Numitor y ya crecidos comenzaron con la fundación de Roma. Hubo una discordancia entre ellos con respecto al lugar en dónde debía ser fundada, mientras Rómulo proponía el Monte Palatino, Remo quería en el Monte Aventino, cada uno de ellos se instaló en estos lugares y

se determinó que el lugar elegido sería el que determinen los auspicios. Rómulo dijo haber visto el vuelo de doce buitres, mientras que Remo el de seis. De ésta manera fue Rómulo quién fundó la ciudad estableciendo la sacritud de los límites a través de ciertos rituales y se estableció la inviolabilidad de éstos por cualquier persona. Debido a que Remo se le dio muerte. Se estableció como fecha hito de la fundación el año 753 a.C.

A partir de la fundación se le pidió a los pueblos vecinos mujeres para poblar la nueva ciudad, como les fueron negadas, Remo hizo una gran fiesta que duró varios días y después de invitar a hombres y mujeres de otros lugares, los embriagaron para desarmar a los hombres y secuestrar a las mujeres. Se libraron cruentas luchas para recuperar a las mujeres, pero al cabo de un tiempo hicieron las paces, se conoció como el rapto de las Sabinas. Después de celebrar la paz se coronó a Rómulo como el primer Rey.

II. La sociedad primitiva. Tribus. Curias. Gentes. Patricios. Plebeyos. Clientes. La organización política. La Lucha entre patricios y Plebeyos. Los Colegios Sacerdotales.

A) Las Tribus

Desde la fundación de Roma y tiempo después hubo tres tribus: Los Ramneses- tenían como jefe a Rómulo-, los Titienses – su jefe era Tatío-, y los Lúceres- cuyo jefe era Lucunio-.

Si bien está discutido, las tres tribus estaban integradas por romanos, sabinos y etruscos, tuvieron sus órganos políticos y administrativos propios, la que se encontraba en relación de inferioridad con relación al resto es la de los Luceres. Está discutido el motivo real de la división y a qué obedece.

B) Las Curias

Era una sub división de la tribu, cada una de ellas tenía 10 curias:

- Cada curia tenía una denominación especial, estaba integrada por patricios;
- Se admitían a los plebeyos; en 545 a.C. llegó al cargo de curius maximus un plebeyo;
- Los miembros de las curias se llamaban curiales, su jefe se llamaba curio;
- Al frente estaba el curio máximo.
- Tenían en común el culto de Juno Quiritis, cada uno con un culto especial que debía sostener todos los miembros.
- Las solemnidades religiosas estaban a cargo de un curio acompañado por un flamen curiales, no se sabe si cada curia estaba dividida en decurias a cuyo frente estaba un decurión.

C) Las gentes

Los miembros de la gens recibían el nombre de patricios y también la de quirites, ésta última denominación se usó más para los sabinos, cuando creció la ciudad de a poco fue desapareciendo.

Al principio todas las gens fueron patricias pero con el paso del tiempo, la llegada de la República, las reformas de Servio Tulio, se fueron formando gens plebeyas como la terentia, y otras patricias y plebeyas como la servilia. Con el paso del tiempo disminuyó el número de patricios, luego el carácter que tuvo la gens fue el de comunidad religiosa, que fue dejada más tarde de lado por la llegada del cristianismo.

- a) Una teoría establece que la Gens es una institución artificial, es decir creada por el legislador, se trata, pues de un parentesco artificial entre varias familias que originariamente eran extrañas unas a otras.
- b) Otra teoría más moderna establece que la Gens era una institución de carácter natural o familiar, abarcaba a las familias provenientes de un tronco común con carácter presunto; el carácter familiar se confundía con el político. Los miembros estaban unidos por:

- 1) Nombre común o *nomen gentilicium*: era el nombre de un antepasado del cual supuestamente todos descendían de él. A éste nomen se le agrega el Cognomen. Se trataba de la rama de la gens a la que pertenecía, también estaba el *agnomen* que era aun nombre añadido, teniendo cada individuo un *praenomen* antepuesto al gentilicio.
- 2) Un culto propio, era una *sacra privata* (no tenía el carácter público de la curia), todo sus miembros contribuían al gasto del culto, y se debían celebrar sacrificios y fiestas anuales en honor de su dios.
- 3) Un jefe *pater* que era el que hacía cumplir las costumbres privadas comunes, las costumbres variaban de una gens a otra.
- 4) Derecho recíprocos a la Herencia y a la curatela entre gentiles cuando faltaban agnados; no se podía salir de testigo contra un gentil.

D) Los patricios

Como se dijo anteriormente formaban parte de la gens, se llamaron así porque los jefes de las gentes formaron parte del senado, o porque tenían su origen en un *pater* divinizado. Era la clase social dominante, más alta, con el goce de los derechos sociales, políticos, económicos y religiosos. En contraposición los plebeyos no gozaban de éstos beneficios por lo que las diferencias entre los dos grupos se irían acrecentando con el tiempo.

E) Los plebeyos

Era la mayoría de los habitantes de Roma, que no eran patricios, de condición libre, no necesitaban ningún patrono que los represente en juicio, sin embargo para accionar se encontraban en inferioridad de condiciones para litigar porque no conocían las solemnidades de las acciones; estaban en inferioridad de condiciones en relación al patriciado, no estaban sometidos a éstos como los clientes. Podían

tener el dominio de las cosas y el *ius commercii*; no tenían derechos políticos; entre patricios y plebeyos no existió el *iusconnubium* por mucho tiempo, no participaban de la religión del Estado Romano, no podían ser sacerdotes.

E) Los Clientes

Se presume que los fundadores de Roma ya tenían clientes, ya que éstos también se encontraban en otras ciudades de Italia, luego se le agregaron los libertos y los descendientes, los extranjeros que pidieron asilo y que se colocaban bajo la protección de los patricios y los habitantes de las poblaciones vecinas conquistadas.

-La condición de cliente se transmitía hereditariamente.

-Desde el punto de vista jurídico eran hombres libres pero no lo eran en la práctica.

-Cada cliente y su familia se encontraban bajo la órbita del patrono y su familia.

-Alquilaban parte de las tierras de sus patronos, se ocupaban de los negocios. Participaban en la religión de los patronos a los cuales pertenecían.

-El cliente tomaba el nombre de su patrono, lo acompañaba a la guerra y le debía respeto, pero el patrón debía protegerlo.

-No podían demandarse recíprocamente en juicio.

-El cliente tenía derecho a tener fortuna propia.

-El patrón tenía el derecho a heredar a su cliente y exigirle ciertas prestaciones para dotar a la hija, pagar impuestos extraordinarios, pagar gastos del culto.

-Por disposiciones de la Ley de las XII Tablas se castigaba al patrono cuando violaba sus obligaciones respecto del cliente, se lo podía declarar sacer (su cabeza quedaba consagrada a los dioses, por lo que cualquiera podía darle muerte).

G) El contrato de hospitalidad

Si bien en cuanto a los extranjeros se distinguía aquellos que pertenecían a los pueblos con los cuales Roma guardaba buenas relaciones diplomáticas (*hostis*), de aquellos extranjeros que pertenecían a los pueblos con los cuales Roma estaba en permanente estado de guerra (*perduellis*, denominación que luego fue usada para los reos que habían cometido crímenes de lesa majestad). Con el paso del tiempo se usó la denominación de *hostis* para designar a todo extranjero sin distinciones.

Los contratos de hospitalidad consistían en un convenio entre un extranjero y un ciudadano, por el cual el primero se ponía bajo la protección del segundo y la de Júpiter Hospitalis.

Se llevaba a cabo por medio de una *sponsio*, se hacía en una tabula hospitalis, generalmente de bronce. Podían ser de dos clases:

- 1) *Hospicium Publicum*: Era el que celebraba Roma con otros estados o ciudades, el ciudadano romano defendía los intereses del huésped si no lo hacía era considerado sacrílego, cuando llegaba Roma se le tenía que dar una habitación amoblada, había que alimentarlo y cuidarlo si se enfermaba además de enterrarlo si moría. Generalmente el huésped viajaba a Roma para defender sus intereses en un pleito legal.
- 2) *Hospicium Privatum*: Solo se podía celebrar con aquellos extranjeros que tuvieran una ciudadanía cierta en otro país, no con aquellos que habían roto relaciones con su patria de origen, en ese caso se transformaban en clientes de un patrono ciudadano romano, lo defendía y lo asesoraba en todos los juicios que tenía, caso contrario se lo castigaba severamente, hay poca diferencia entre los contratos de hostilidad y de clientela. La condición de *hospitium* se transmitía hereditariamente, siempre y cuando las partes no renunciaran a llevarlo a cabo.

H) La organización política primitiva

Había tres órganos esenciales: el rex, la asamblea popular y el senado.

- 1) El Rey: Los siete reyes romanos fueron:
 - a) Rómulo, el fundador de Roma, Numa Pompilio: que organizó el culto;
 - b) Numa Pompilio: organizador del culto.
 - c) Tulio Hostilio: destruye Alba Longa;
 - d) Anco Marcio: Al crear el Puerto de Hostia permite que Roma tenga una salida al mar;
 - e) Tarquino el Antiguo: construyó obras: la cloaca máxima, el Foro, el Circo, manda hacer muchos monumentos, entre otras obras; (de origen etrusco).
 - f) Servio Tulio; hijo adoptivo del anterior, nacido de una esclava que lo sucede cuando es asesinado (de origen etrusco).
 - g) Tarquino el Soberbio (de origen etrusco).
- 2) El *interrex*: Había un *interrex* o senador nombrado que convocaba a los comicios *curiados* (integrados por los jefes de las gentes o *patres*) y proponía un candidato que los comicios aprobaban. El Rey era el general del ejército en tiempos de guerras, nombraba funcionarios en la administración del Estado. Tenía facultades en el orden religioso que eran concedidas por los comicios *curiados*.

III. La asamblea popular

- 1) Primera clase de comicios: Comicios por curias
 - Denominada también comicios *curiados* en las épocas más antiguas, estaba compuesta por tres tribus, cada una se dividía en diez curias, siendo un total de treinta curias.
 - Convocadas por el rey o subsidiariamente por el *interrex*.
 - Se realizaban los días 24 de marzo y 24 de mayo, aunque en casos de urgencia el rey podía convocarlos;

- El rey hacía la *rogatio* y el pueblo aprobaba o rechazaba sin discutirla, cada curia tenía un voto, la mayoría estaba formada por dieciséis curias. Se reunían en la parte del foro llamada *comitium*, para deliberar debían estar favorecidos por los auspicios.
- Para tener fuerza de ley debía ser ratificada por el senado.
- El principal asunto que debían resolver era la elección del rey y de diversos asuntos políticos.
- En tiempos de la República la presidencia de los comicios *curiados* le corresponde al Pontífice Máximo, pero la puede ejercer el cónsul, disminuyen sus atribuciones y se conserva el *Imperium* y la autorización para testar.
- Antes de votar, dentro de cada curia se hacía una votación para saber la opinión de la mayoría.
- Las leyes sancionadas se denominaban leyes *curiadas*, quedaban perfeccionadas con la *auctoritas patrum* o sanción del Senado.

2) Segunda clase de comicios: Comicios por centurias

Aparecieron como consecuencia de la reforma de Servio Tulio que dividió al pueblo en centurias, cada una de ellas tenía un voto, comenzaba la votación por las 18 centurias de caballeros y siguiendo por el de la primera y las otras clases; si los caballeros y la primera clase votaban en igual sentido ya tenían más de la mitad de los votos y la elección estaba decidida.

- a) En tiempos de la monarquía convocar a estos comicios era una atribución del rey, eran reuniones que se hacían en el campo de Marte con carácter militar.

Con atribuciones distintas a la de los comicios *curiados*, declaraban la guerra, actuaban en los delitos de alta traición, comparten la elección del rey con los *curiados* con el paso del tiempo, siempre con el *Imperium* de ésta última clase de comicios.

b) En tiempos de la República estos comicios

-Eran convocados por un magistrado que tenía *Imperium*, como los cónsules o los magistrados que los reemplazaban;

-los comicios judiciales podían ser presididos por el Pretor y los electorales, si estaba vacante el consulado por el *interrex*. -Sus atribuciones eran: elegir cónsules y demás funcionarios, votar las leyes, declarar la guerra, decidir la paz, conocer las causas criminales, la *provocatio ad populum* o apelaciones a las sentencias que importaban castigo corporal o la muerte.

c) Reformas

Estos comicios fueron reformados en el siglo III a.C. el número de centurias fue de 373 había aumentado a 35 el número de Tribus y cada una tenía 10 centurias, se le sumaban las 18 centurias de caballeros y los cinco de ingenieros y músicos. No estuvo en manos de los caballeros y de la primera clase decidir la votación, para lo cual debían votar por lo menos las tres primeras clases. Se determinó que las votaciones no debían empezar por las centurias de caballeros, sino por aquella centuria de la primera clase que le tocara (centuria *praerrogativa*).

3) Tercera clase de comicios: Los Comicios por Tribus

La reforma de Servio Tulio dio origen a una clase según el domicilio; la reforma había dividido a la ciudad en cuatro tribus urbanas: Suburbana, Esquiliana, Collina, Palatina; la parte no comprendida de la ciudad se dividió en tribus rústicas, al principio fueron 16 y más tarde 35. El nombre de las Tribus rústicas estaba dado por el nombre de la ciudad en que se hallaban: Falerina, o por los nombres de las viejas gentes como la Cornelia.

La diferencia entre los conciliábulos y los comicios por tribus, es que estos últimos estaban presididos por un magistrado patricio. Tenían a su cargo la elección de los magistrados menores y los miembros de los colegios sacerdotales. Los comicios centuriados se

dedicaban a declarar la guerra y ya no ejercían otras potestades, los principales órganos legislativos fueron los comicios por Tribus.

IV. El senado

Al principio fue la Asamblea de Ancianos, que tenía función de cuerpo consultivo. El primitivo senado romano fue la representación de la gens compuesta por cien senadores, en tiempos de Tarquino el Antiguo aumentó a trescientos. Al principio los jefes de las gens integraban el senado. Luego eran elegidos por el *Rex*, por lo tanto el rey debía ser un patricio.

- 1) Atribuciones
- b) Preparaba las leyes que sometían a los comicios curiados, las confirmaba por medio de la *auctoritas patrum*;
- c) Entendía en asuntos religiosos, políticos, internacionales que afectaban a la seguridad del Estado, en estos casos era obligatorio que el Rey consultara al Senado y en la declaración de guerra su voto era decisivo. Los senadores también ejercían funciones de *interrex* en caso de vacancia real, no pudiendo permanecer en el cargo más de cinco días. Si no se había elegido rey, le sucedía otro senador, la designación del primer *interrex* se hacía por sorteo y éste designaba al que lo sucedería.

V. Alcance de las Reformas de Servio Tulio

La tradición atribuye a Servio Tulio haber introducido en Roma la nueva constitución de clases y centurias. El interés radicaba en que los patricios querían que fueran incorporados a las filas del ejército los plebeyos, existía esa necesidad. La nueva división del pueblo se basaba en su fortuna y no en su origen, tanto los patricios como los plebeyos ingresaban al ejército, debían pagar impuestos, también intervenían en la sanción de las leyes. Creó geográfica y administrativamente 4 tribus urbanas y 16 rústicas, que con el paso del tiempo

aumentaron a 35. Se estableció el censo, había obligación de declarar bajo juramento la fortuna que el declarante tenía, el nombre y edad de su mujer e hijos; quién no se censaba se castigaba con la esclavitud y sus bienes eran confiscados, las declaraciones realizadas en un censo se inscribían en un registro (*caput*) que debía renovarse cada cinco años. Para medir la riqueza se toman en cuenta los ases, si bien es cierto que Servio Tulio creó el *aes signatum*, que era una barra de metal con una marca, no es posible que haya sido una moneda acuñada, pues no existió como tal sino en la época de los decenviros.

La división en clases y números de centurias era:

CLASES	RIQUEZA	Nº DE CENTURIAS
Caballeros	Census Maximus	18
1º clase	100.000 ases	80
2º clase	75.000 ases	20
3º clase	50.000 ases	20
4º clase	25.000 ases	20
5º clase	11.000 ases	30
Obreros, carpinteros y armeros (<i>tignarii et aerarii</i>)		2
Músicos (<i>Proletarii et cornecines</i>) Proletarii et capite censi		2 1
		Total..... 193

Tito Livio refería el número de centurias en 194, ya que hay que agregar una de accensi *velati*, llamados también desvestidos ya que cuando moría alguien en combate los sustituían poniéndose las ropas del difunto. Los *proletarii* y los *capite censi* no prestaban servicio militar alguno, los ciudadanos que tenían menos de mil quinientos ases estaban exentos del impuesto.

Cada una de las clases estaba dividida en igual número de centurias de *seniores*; eran los que tenían de 46 a 60 años de edad; y *juniores*; éstos últimos eran los ciudadanos de 18 a 46 años.

La centuria era una verdadera unidad política, representaba un voto en los comicios y de ésta manera entre la clase de los caballeros y la primera ya tenían mayoría, ya que eran 98 contra 95, eran la base de la organización militar, el ejército se dividía en dos contingentes: el de los juniors que luchaban en campo abierto y el de los *seniores* que tenían a su cargo la defensa de la ciudad. Los plebeyos podían llegar a ser oficiales, centuriones y tribunos militares.

VI. Los Colegios Sacerdotales

Pontífices, sus atribuciones; calendario, interpretación La tradición atribuye la creación de los pontífices a Numa, ya que era el sacerdote máximo, pero el caso de que como rey estuviere ausente, surgió la necesidad de nombrar sacerdotes y no pudiera hacer sacrificios.

- Las funciones de sacerdote eran de carácter vitalicio.
- Al principio el colegio se componía de tres miembros y luego de cinco.
- Dentro del Colegio estaban los pontífices máximos, que eran elegidos por el rey; y los pontífices menores que eran elegidos por el colegio.
- Las vestales dependían del colegio de los pontífices.
- Velaban por el cumplimiento general del culto, con atribuciones en el campo político y de la vida civil ya que era una época que lo religioso regía a lo jurídico.
- Los pontífices tenían a su cargo la confección del calendario, porque guardaban los secretos de las medidas y de los números.
- la determinación de los días fastos y nefastos tuvieron importancia en la realización de los actos privados.
- Las *legis actionis* no podían celebrarse un día nefasto, prohibición válida para actos entre particulares, podía ocurrir que en un mismo día un acto era nefasto a la mañana y fasto a la tarde.

- Con la publicación que realizó *Cneo Flavio* de las fórmulas procesales y la publicación de los días fastos y nefastos, los pontífices perdieron el monopolio que hicieron de la ley.
- El Pontífice Máximo debía consignar los principales acontecimientos del año en una especie de tabla blanca que exponía en su casa, así quedaban confeccionados los *Annales Maximi*, obra que era consultada por los historiadores.
- Los plebeyos no podían ser elegidos pontífices.
- Abolida la monarquía el colegio eligió libremente a sus miembros, los patricios así tenían más poder político.
- Los plebeyos consiguieron entrar al colegio por medio de la Ley *Olgunia*, había 8 miembros, la mitad patricios y la mitad plebeyos.
- El Pontífice máximo era elegido por los comicios por tribus.
- La Dictadura de Sila elevó a 15 el número de miembros.
- En el Imperio el Emperador era el Pontífice Máximo, y quién proponía los miembros al colegio.

1) Los Augures

Eran los que se encargaban de realizar los auspicios, se trataba de la respuesta favorable que podían dar los dioses ante una consulta que se les formulaba previo a celebrarse un acto, para saber si éste era o no válido. Los augurios podían ser señales del cielo, el grito y vuelo de las aves, el apetito o inapetencia de los pollos sagrados, las posiciones de los mamíferos y reptiles y por los acontecimientos imprevistos o extraordinarios.

Existieron desde los orígenes de la Ciudad de Roma, había augures oficiales y particulares, contaban con mucho poder porque podían suspender en cualquier momento las asambleas populares, anular la elección de los magistrados o dejar sin efecto una resolución tomada sobre cualquier asunto de la vida de un Estado, en el caso de que los auspicios fueran desfavorables. Los magistrados consultaban a los augures oficiales, su cargo era vitalicio y no perdían por cometer delitos ya que ellos guardaban el secreto de la República.

Al principio solo fueron augures los patricios, con el paso del tiempo lo fueron los plebeyos, usaban dos clases de libros: el de rituales en el que se indicaba el ceremonial y el libro de comentarios, en el cual se resumían los principios fijados por la ciencia augural. Fueron suprimidos por el Emperador Teodosio.

2) Los feciales y otros colegios

Los Feciales eran magistrados que tenían carácter religioso, representaban al pueblo en la vida pública internacional. Tenían funciones políticas, judiciales y religiosas, controlaban el cumplimiento de los tratados; la guerra debía ser justa, legítima y legal, siempre y cuando se cumplieran con los ritos feciales, si se consideraba que eran necesario ir a la guerra, una comisión integrada por cuatro miembros y presidida por un *pater paratrus* desde la frontera lanzaba una lanza ensangrentada o una flecha y de ésta manera se iniciaba la guerra. Para preparar los tratados de paz se designaba dos feciales, el *ius feciale* se referían a las inmunidades que tenían en Roma los embajadores extranjeros, la extradición, la declaración de guerra y la paz.

El colegio de los feciales estaba integrado por veinte miembros que al principio eran designados por la curias, posteriormente, los plebeyos podían integrarlo. Tenía un presidente llamado *Magister Fetralum*. Además de los mencionados existían el de los II *Viri Sacrorum*, que tenían a su cargo los libros sibilinos (después de XV *Viri SacrisFaciundis*) y los III Viri, más tarde VII *ViriEpulonum*, ayudantes de los pontífices en los festines sagrados.

VII. Las Luchas entre patricios y plebeyos: causas y consecuencias

A continuación se mostraran los diversos aspectos que plantearon controversias entre las distintas clases sociales en Roma, se tratará de determinar su origen, desarrollo y consecuencias, para entender a la vez la evolución de las instituciones jurídicas, sin incurrir en detalles exhaustivos de éstas últimas.

a) La división más importante de la sociedad desde los orígenes:

Los Patricios y Plebeyos

Marcó uno de los hitos más importantes de la sociedad romana, En los primeros siglos era impensable que patricios y plebeyos tuvieran un mismo rango social. Si bien se hacía la distinción entre las “gentes” o clanes de patricios y las familias plebeyas, no integradas en principio a ésta organización gentilicia. Tito Livio vinculaba su pertenencia a las gentes con la posesión de los auspicia, mientras que consideraban a los plebeyos como simples *terrae filii*, y en cambio Aulo Gelio se refería a la plebe como la parte de la ciudadanía no incluida en las gentes patricias.

Mientras tanto el patricio es el hombre rico, poderoso, guerrero, magistrado, cónsul, sacerdote, pater, agricultor, comerciante, plagado de la *idiosincrasia romana*.

Si bien la salida de los reyes de la que luego se hará referencia no significó la expulsión de los etruscos, sí marcó un cambio institucional: el advenimiento de la aristocracia a las magistraturas y Asambleas. Los primeros colegios de magistrados incluyen nombres etruscos y plebeyos, pero luego un sector monopoliza el poder a partir del año 485 a. c. también el sacerdocio y las magistraturas, son los patricios.

La concepción romana según la cual *Plebei gentes non habent*, o sea, los plebeyos no estaban excluidos de las gentes.

La búsqueda de conquistas sociales por parte de la clientela y su oposición al patriciado.

Se hará una breve referencia histórica para la comprensión de cómo se fueron originando las mismas:

El primer Rey se caracterizó por lo siguiente:

- quiso aumentar su poder y liberarse del senado,
- contó con el apoyo de las clases inferiores,
- finalmente fue asesinado

La aristocracia quiso abolir la realeza, el *populus* se opuso a ser gobernado solo por patres.

Entonces los patricios proponen:

- elección por el senado
- apoyo de la asamblea patricia de las curias
- apoyo a los augures patricios

En éstas condiciones fue elegido el segundo rey: Numa (que era el que convenía al patriciado), era más jefe religioso que político.

El tercer Rey:

- Combinó ambas funciones la religiosa y la política;
- fue guerrero, quiso debilitar la religión
- Recibe en Roma a muchos extranjeros (que eran excluidos por la religión), y habitó con ellos en el Monte Celio;
- Distribuye tierras entre los plebeyos
- Es Acusado por los patricios de descuidar, alterar y modificar los ritos, como consecuencia de ir en contra del patriciado muere asesinado.

El Senado recupera autoridad y elige al cuarto Rey, Anco: siempre conveniente su actuación a los intereses de los patricios.

El quinto Rey, Tarquino:

- llega al poder con ayuda de las clases inferiores
- enemigo de las antiguas familias, crea nuevos patricios
- poco religioso, incrédulo de los augures;
- altera la constitución religiosa de la comunidad

Cuando Roma Extiende sus fronteras una de las consecuencias fue la existencia de una gran cantidad de extranjeros dominados que aumentaron el número de la plebe no clientes, así comienzan las luchas por la conquista del reconocimiento de sus derechos. No tenían cargas públicas ni la administración de la ciudad. Tarquino el Antiguo fue el primero que intenta solucionar la desigualdad, y quiere crear tres tribus nuevas compuestas de plebeyos, pero la oposición del Augur Navius, no le permitió cumplir con éste objetivo, conservándose entonces la antigua estructura de las tres tribus y de

las treinta curias, pero aumenta el número de plebeyos que las podían integrar que incorporadas a los patricios se llamaron menores gentes.

El sexto Rey:

- Se apodera de la realeza por sorpresa;
- El senado no lo reconoce como rey legítimo;
- Concede a las clases inferiores tierras, puestos en el ejército y en la ciudad;
- Muere degollado.
- Se establece entonces una lucha social entre la aristocracia y los reyes, éstos últimos era apoyados por la plebe y los clientes, que eran las clases más numerosas. La Aristocracia se veía atacada por sus clientes.
- En el año 166 con la llegada de Servio Tulio, ya deja de existir la antigua organización patricia surgida de la distinción en tres tribus primitivas y de los comicios por curias, crea una nueva división del pueblo fundada en el origen de la fortuna de sus miembros y abarcaba a toda la población, así se llamó a los plebeyos a concurrir al servicio militar y a cumplir con las cargas impositivas
- La decisión votada en los comicios por centurias, *lex curiata* no era obligatoria hasta que no fuera aprobada por el senado (*auctoritas patrum*), de éste modo se veía el poder del patriciado, ya que las 18 centurias de caballeros y las ochenta centurias de la primera clase estaban integradas por la parte más pudiente de Roma.

El séptimo rey es el segundo Tarquino: Hace todo el daño que puede a los patricios; luego ausente de Roma él y su ejército, la ciudad está en poder momentáneo de los patricios: El Prefecto de la ciudad: el Patricio Lucrecio, que tenía el poder civil en ausencia del rey; y El Jefe la caballería: El Patricio Junio, que tenía el poder militar después del rey.

Ambos preparan la insurrección y se reúnen en la Villa de Colacia, el pueblo se subleva por incitación de éstos y van a la ciudad de

Roma que también se subleva. De ésta manera es destituido Tarquino y su consecuencia la abolición de la realeza.

Durante los años que siguieron a la expulsión de los reyes el poder de la aristocracia fue absoluto. Solo el patricio ejercía funciones sacerdotales en la ciudad, no se suprimió la asamblea por centurias a la que no tenían acceso los plebeyos.

- Las clases inferiores no tardan en reconocer su importancia, surgen rivalidades de los jefes de familias para debilitarse recíprocamente, junto a otros factores que se dan a lo largo del tiempo la familia agnaticia y la primogenitura se diluyen en su conformación interna produciéndose modificaciones que llevaron a la reducción de los lazos familiares, y de a poco surgieron los vínculos cognativos.

b) Mejoras en las condiciones de la clientela como consecuencia de su emancipación

En lo que respecta a la clientela, era una cuestión necesaria la recíproca necesidad que el pobre tiene del rico y el rico del pobre, esto creó a los servidores o esclavos son lo mismo en este régimen de dominación. Se concibe que el principio de un servicio libre y voluntario pudiendo cesar a capricho de su servidor (si bien el amo le podía dar la libertad, no salía por ello de la familia). Por otra parte, la religión doméstica no permite que la familia admita a un extraño. Es necesario que el servidor venga a ser por cualquier medio, miembro y parte integrante de la familia. Hay una iniciación del recién venido al culto doméstico. Tenía que permanecer en ella sino era castigado. Con el nombre de liberto o cliente se establecían las relaciones de patronato de carácter hereditario. Así se formó en el seno de la familia cierto número de pequeñas familias clientes y subordinada.

La clientela y el plebeyado son dos grupos distintos que están en estado de sumisión; Los clientes eran numerosos veían una sociedad y leyes que los excluía, aparece el sentimiento de clase y buscan la libertad, los amos se sintieron presionados y debieron ceder; así poco a poco ya no creen legítima su autoridad, la confunde o acaba

con renunciar a ella, la clase inferior era útil, por lo tanto había que satisfacer los reclamos, y la condición de los clientes mejoró poco a poco. Al principio vivían en la casa del amo cultivando el suelo, que no cultivó para el amo sino para sí mismo, con la condición de un censo, al aprovechar los cultivos su vida fue más libre, así convertido en poseedor sin poder ser propietario, era una práctica común del sometimiento de clase.

De a poco consiguió las siguientes ventajas:

- Más tarde se convierte en propietario accidental del lote con tal de que contribuya con todos los gastos que incumben a su antiguo dueño;
- Tenía la obligación de pagar el rescate a su patrono, la dote de su hija o las multas judiciales;
- El cliente transmite a su hijo lo que tiene al morir;
- Si no deja hijos puede testar;
- Lentamente se distanció del patrono.

Servio Tulio reformó el ejército en beneficio de los clientes; en el año 472 a. c. el número de clientes era considerable, la plebe se quejaba de que en los sufragios en los comicios por centurias los clientes apoyaban los intereses del patriciado. Es en la misma época que la plebe se negó a alistarse por eso los patricios recurrieron para esa tarea a la clientela. En el año 372 quedaban muy pocos clientes, que se fusionaron con el plebeyado.

c) Otro cambio de gran importancia: El surgimiento de una nueva organización social, repercusiones

Los cambios anteriores establecieron dos clases bien diferenciadas; la aristocracia y el resto de la población. A la vez el pueblo era muy numeroso sin jefe ni organización, pero poco a poco la clase inferior tiende a mejorar, la tierra ya no satisfacía completamente sus necesidades, se le da importancia a lo bello y al lujo, florecen las artes, la industria, el comercio, el acuñamiento de la moneda significó que no estaba sometida a las mismas condiciones que la propiedad de la

tierra, el hecho de que pasara de mano en mano sin ningún tipo de formas hacía que llegara a los plebeyos, por eso se forma en la población una clase rica.

Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que la familia plebeya encendiera un fuego sagrado de la misma manera que lo hacía la patricia, también accedió a, los templos de la ciudad, pero no ejercía el culto doméstico.

La clase superior no podía permitir esta intromisión del resto de la población, a lo que ésta se vio obligada a levantar templos propios, así sobre el Aventino el templo consagrado a Diana.

Por la situación en la que se encontraba Roma con respecto a los latinos, sabinos y etruscos la condenaba a una constante guerra por lo que los reyes convocaban a los extranjeros, sin fijarse el origen, así acrecentaban el número de plebeyos, el cliente que lograba separarse de la gens se convertía el plebeyo. El patricio que cometía matrimonio desigual o cometía una falta que implicaba degradación, caía en la clase inferior.

Los reyes siempre se apoyaron en la plebe por lo que ésta última y la nobleza se vieron con los mismos enemigos, los patricios. Así se establecieron alianzas tácitas. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales la nobleza no estaba unida al patriciado? Si bien era un patriciado amplio comprendía además de patricios verdaderos, aquellos plebeyos que han salido del patriciado, y aquellos otros que a los patricios se equiparan por los cargos públicos que ocupan, el noble que por medio de la emancipación o separación hubiere dejado de pertenecer a la familia perdía sus derechos de nobleza, pero conservaba su nombre familiar y además seguía siendo un hombre 'conocido' (nobilis). También designó a los plebeyos que conforme a la Ley Licinnia, lo graban ocupar puestos públicos reservados hasta entonces a los patricios. No tiene los privilegios jurídicos que al patriciado pertenecen.

Recién durante el reinado de Servio se vieron los progresos de la plebe; su primera reforma fue dar tierras no del *ager romanus*, sino de las conquistadas al enemigo, publicó leyes referidas a obligaciones

que el plebeyo podía contraer con el patricio. La plebe fue admitida en las nuevas tribus, el plebeyo celebraba sus fiestas religiosas como las celebraba el patricio los sacrificios de su gens y su curia. El pueblo ya no se ordenó por curias, todos los hombres libres de Roma que formaban parte de las tribus nuevas.

Sin embargo la plebe viéndose en la situación de inferioridad en la que se encontraban decidió salir de Roma, fueron al Monte Sacro, fuera de los límites de Roma, así los patricios convivieron con los clientes que les servían, pero a la plebe la necesitaban.

En el año 260 los plebeyos salen de Roma y van al Monte Aventino, así negocia con los patricios la admisión de dos magistrados plebeyos: los tribuni plebis, son declarados inviolables y con un derecho de veto dentro de Roma y en un radio no superior a una milla de la ciudad, en cuanto a las decisiones de los magistrados, de los cónsules y del senado.

Ello no significó la concesión de derechos a la plebe, solo se había establecido la inviolabilidad de los tribunos -ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris no cuisset, eius caput iovi sacrum esset, familia ad aedem cereris liberi liberaeque venum ire- (Lex Valeria Horatia, año 449).

Así los tribunos reunían a la plebe en asambleas, para deliberar y votar las decisiones llamadas plebiscitos, obligatorias para ellos, no asistían a ellas los patricios. Luego los tribunos convocaron a los plebeyos sobre el foro según el domicilio de ellos o sea por tribus, así en el año 283 aproximadamente los magistrados patricios en vez de reunir al pueblo por centurias sobre el campo de Marte, los convocaron por tribus sobre el foro, aparecen entonces los comicios por tribus, la unidad del voto en estas nuevas asambleas era la tribu, con mayoría plebeya. Luego obtiene del patriciado una ley fija conocida y aplicada a todos por igual, fue la ley de las XII tablas.

Los Tribunos por su cuenta empiezan a convocar a la plebe, como no tenían participación en el senado empiezan a sentarse en la puerta de la sala, luego en el interior (si el tribuno entraba al senado nadie

podía hacerlo salir), no tenían derecho a juzgar a los patricios pero lo hacían incluso los condenaban, una vez iniciada la asamblea nadie la podía disolver. Si bien la nueva normativa fue un avance importante, los plebeyos seguían excluidos de las magistraturas y no podían contraer matrimonio civil con los patricios, fue hasta que en el año 309 aproximadamente el tribuno Canuleyo, consigue que se vote la Lex Canuleia, consiguiéndose así el triunfo de la plebe en cuanto a que se permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos.

VIII. Nueva etapa de reorganización de la sociedad

De trescientas familias patricias que había en tiempos de los reyes, luego de las continuas guerras no quedan más que un tercio de ellas, también exterminó a la plebe primitiva, después de la conquista de Samnio.

Sin embargo persistieron las desigualdades el desarrollo del comercio fue en beneficio del rico, en cuanto a las industrias todos los trabajadores eran esclavos, los ricos tenían en sus casas talleres para tejedores, cinceladores, armeros, todos esclavos.

La situación anterior a los Gracos se caracterizó en general por la explotación descontrolada de las provincias e incluso de los países sometidos por los gobernadores y los publicanos. Éstos operaban con plena libertad y sus abusos quedaban impunes. En cuanto a Roma se encontraba dividida en tres bandos: el de la nobleza o familias senatoriales (oligarquía gubernamental); el de los caballeros dedicados a actividades comerciales y hombres de negocios en general que poseían bienes muebles y formaban parte de las sociedades de publicanos, y el popular, formado por el proletariado urbano y rural.

En el campo agrícola el hecho de acudir al servicio militar ocasionaba la ruina de la pequeña o media propiedad, aun cuando en los últimos tiempos de la república hubo jornaleros y arrendatarios agrícolas, decae el cultivo cerealero, los campos son abandonados por quienes tienen pocos recursos para asentarse en Roma y aumentar el número de la plebe, crecen las actividades comerciales y el tráfico de